

1500856-69.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo César Ribeiro Meireles

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/09/2022

...

Primeiramente, cumpre observar que o crime de tráfico, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 possui natureza múltipla, ou seja, sua tipificação descreve mais de uma conduta, em relação à mesma vítima, que neste caso é a saúde pública. Essa classificação é de suma importância, pois o tráfico não consiste em apenas no ato de vender drogas a alguém.

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá 1ª Vara

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 2124-9664, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat1@tjsp.jus.br

#### CONCLUSÃO

Em 09 de setembro de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo César Ribeiro Meireles. Eu, \_\_\_\_\_, Escr., lavrei este termo.

#### SENTENÇA

Processo nº:

1500856-69.2020.8.26.0621 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE EDUARDO NUNES

Juiz de Direito Dr.: Paulo César Ribeiro Meireles

VISTOS OS AUTOS.

JOSE EDUARDO NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Presentante do Ministério Público, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de outubro de 2020, por volta de 21 horas e 59 minutos, na Rua Venezuela, n. 01, Flamboyant 02, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, drogas consistentes em 56,4g (cinquenta e seis gramas e

quarenta decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta da denúncia, nas circunstâncias de tempo e local supra, o Réu realizava tráfico de drogas em via pública, quando foi surpreendido por Policiais Militares que realizavam patrulhamento no local.

Consta que, ao avistar os Milicianos, o Réu empreendeu fuga do local, tendo dispensado no solo um frasco e o montante de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em dinheiro, fruto da traficância.

Todavia, os Policiais Militares conseguiram capturar o Réu, tendo apreendido, em seguida, o invólucro mencionado, no qual havia 59 (cinquenta e nove) pinos eppendorf e o valor em dinheiro citado.

Ato contínuo, o Réu foi preso em flagrante delito.

Vieram aos autos, Auto de Prisão em Flagrante (pág. 01); Termos de Depoimento (págs. 02/03); Termo de Interrogatório (pág. 04); Boletim de Ocorrência (págs. 08/10); Auto de Exibição e Apreensão (pág. 11); Laudo Pericial (págs. 13/14, 16, 62/64, 69/71, 87/89, 95/97); Inquérito Policial (págs. 65/66); Folha de Antecedentes (págs. 21/26, 82/85).

A denúncia foi recebida às páginas 57 a 59.

Convertida prisão em flagrante em prisão preventiva (págs. 36/41, 47/48, 51/52).

Citado o Réu (págs. 67/68, 74/75, 90/91), este apresentou defesa preliminar às páginas 104 a 106. Alegou que há ausência de indícios de que o Réu pratique venda de substâncias ilícitas ou fornecimento destas. Alegou que os entorpecentes não foram encontrados em poder do Réu. Reservou-se ao direito de rebater o mérito no decorrer da instrução. Requereu que seja revogada a prisão preventiva. Requereu a oitiva das mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial. Requereu a oitiva de três testemunhas.

Confirmado o recebimento da denúncia (págs. 114/116).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 114/118, 122/125, 127/134).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação (págs. 135/137).

Designada nova audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 139/149).

Em nova audiência de instrução, debates e julgamento, houve o interrogatório do Réu (págs. 149/150).

Em alegações finais, o Doutor Promotor requereu a procedência da ação, afirmando que a existência do crime restou devidamente comprovada, bem como a sua autoria resultou indiscutível. Quanto à dosimetria da pena, requereu que seja observada a reincidência do Réu. Requereu que o início da execução se dê em regime fechado, dada a natureza dos delitos, sem perspectiva de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos em função de os crimes serem equiparados aos de natureza hedionda (págs. 161/167).

Em alegações finais, a Defesa do Réu, por sua vez, postulou pela absolvição do Réu, alegando que há fragilidade das provas arrecadadas nos autos. Alegou que as únicas provas são os testemunhos dos policiais. Requereu a absolvição do Réu.

Subsidiariamente, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal e que o Réu possa apelar em liberdade (págs. 175/178).

Vieram-me conclusos os autos.

Este, em síntese, é o relatório.

FUNDAMENTO.

Cuida a espécie presente de denúncia oferecida em razão de crime de tráfico de drogas pelo Réu, que trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, drogas consistentes em 56,4 g (cinquenta e seis gramas e quarenta decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ausentes preliminares, quanto ao mérito, no que diz respeito à materialidade do delito, observamos que as substâncias entorpecentes foram constatadas como sendo realmente as drogas em questão, Cocaína, prévia e definitivamente, de acordo com o Laudo Pericial (págs. 13/14, 16, 62/64, 69/71, 87/89, 95/97). Ademais, a materialidade também restou claramente demonstrada a partir de Auto de Prisão em Flagrante (pág. 01); Termos de Depoimento (págs. 02/03); Boletim de Ocorrência

(págs. 08/10); Auto de Exibição e Apreensão (pág. 11); e Inquérito Policial (págs. 65/66).

A autoria, por sua vez, é igualmente certa e indubitosa a partir do que nos autos consta, senão vejamos:

R.L.F.L., Policial Militar, afirmou que, em patrulhamento, a equipe policial adentrou o Flamboyant 1 e a outra equipe o Flamboyant 2. Afirmou que o Réu percebeu a outra viatura e correu, sem perceber, em direção à equipe policial. Afirmou que, quando o Réu visualizou a segunda equipe, este jogou um pote de maionese no chão e correu. Afirmou que havia cerca de R\$ 280,00 muito próximo do Réu. Afirmou que havia entorpecentes no interior do pote. Afirmou que o Réu negou que os entorpecentes lhe pertencessem.

B.L.S.G., Policial Militar, coadunou com as informações prestadas pelo seu colega de farda.

O Réu, JOSE EDUARDO NUNES, em seu interrogatório, alegou que mora no bairro Flamboyant 01. Alegou que sua esposa havia pedido para ele comprar um refrigerante no Flamboyant 02. Alegou que não estava com dinheiro, tendo alegado que iria comprar o refrigerante fiado. Alegou que “uns três moleques” passaram correndo e jogaram um pote de maionese no chão. Alegou que os policiais o revistaram e interrogaram. Alegou que os policiais estavam no encalço desses moleques antes de pará-lo. Alegou que os entorpecentes foram encontrados no meio da rua. Alegou que o policial disse que um dos menores que fugiram era o chefe da biqueira e que, como não daria em nada, disse que iria prendê-lo no lugar dele.

Primeiramente, cumpre observar que o crime de tráfico, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 possui natureza múltipla, ou seja, sua tipificação descreve mais de uma conduta, em relação à mesma vítima, que neste caso é a saúde pública. Essa classificação é de suma importância, pois o tráfico não consiste em apenas no ato de vender drogas a alguém.

Vale lembrar que as afirmativas feitas pelos agentes policiais têm a presunção “juris tantum” de serem verdadeiras, posto que estão a serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão e manter a ordem pública, cabendo a quem alegar eventual falsidade ou conduta ilícita da parte dele, prová-la ou, ao menos, trazer ao juízo indícios coerentes da dita irregularidade, o que não aconteceu no presente caso.

Desta forma, observo que o delito de tráfico está devidamente caracterizado e o Autor corretamente identificado, conforme veremos nas linhas a seguir.

Neste sentido:

"Quanto ao depoimento de policiais, presume-se que agem eles no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, havendo que se repudiar sua palavra somente quando em flagrante dissonância com os demais elementos de convicção trazidos ao processo." (TJSP, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Devienne Ferraz, votação unânime, RT 727/473).

Portanto, com relação à alegação da defesa de que os testemunhos dos policiais civis são incoerentes, esta não merece prosperar, haja vista que, estes apresentaram coerência entre si e com as provas apresentadas.

Destaco que não haveria motivos para que os policiais simplesmente parassem de perseguir os reais traficantes para prender o Réu, como narrado por este, haja vista que, os policiais trabalham para garantir a ordem pública. Ou seja, seria incoerente deixar os reais criminosos empreenderem fuga para prender um transeunte inocente e mais ainda acreditar na versão estapafúrdia do Réu e desacreditar servidores públicos dedicados.

Ademais, os policiais afirmaram que havia diversas pessoas no local. Caso os fatos tivessem ocorrido como o Réu narrou, ou seja, com três indivíduos culpados, teria havido testemunhas. Nesse sentido, a defesa não trouxe nenhuma testemunha acerca das alegações do Réu ou qualquer outra prova nesse sentido.

Desse modo, quanto à tipicidade tenho que é a exata correlação dos fatos de que se ocupa este processo à norma penal invocada na exordial, pouca coisa resta para dizer, já que o acontecido se ajusta perfeitamente à situação criada em abstrato pelo legislador penal, senão vejamos:

Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Pena - reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Posto isso, passo a dosar a pena aplicável à espécie, com base nos artigos 59 e 60 do Código de Penal.

#### I - PENA-BASE

Considerando e atendendo à culpabilidade, tenho que não se revestem os fatos praticados de reprovabilidade anormal ou exacerbada, tendo o dolo sido regular ao tipo; aos seus antecedentes, observo que o Réu possui duas condenações específicas transitadas em julgado, da qual não se passaram 05 anos entre o trânsito e o crime atual, motivo pelo qual uma será utilizada para fins de maus-antecedentes e outra na fase seguinte como reincidência (págs. 21/22); à conduta social, não se tem elementos nos autos, pois diz respeito à forma com que se portava no meio em que vive; à personalidade, igualmente não se dispõe de elementos capazes de traduzir a estrutura psíquica do Réu; aos motivos do crime, não há especificação quanto aos motivos que o levou ao delito, possivelmente o lucro fácil, mas tal motivação não é alheia aos delitos do gênero, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância em desfavor do Réu; às circunstâncias do crime, respeitante estas, não há nada que refuja à normalidade desse tipo de delito; às consequências do crime, são de extrema gravidade, contudo, tais consequências são inerentes aos delitos dessa natureza; e, finalmente, quanto ao comportamento da vítima, saliente-se que ela em nada contribuiu para esse tipo de conduta delituosa, aliás, a coletividade é a titular do bem jurídico protegido (saúde pública). Deixo, portanto, de considerar esta circunstância.

Assim, ante a existência de maus-antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, aumentando-a em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa pecuniária em 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei n. 11.343/06).

#### II - PENA PROVISÓRIA

Passo à análise das agravantes e das atenuantes e fixação da pena provisória e, neste sentido, como já anotado na fase anterior, o Réu possui duas condenações específicas transitadas em julgado, das quais não se passaram 05 anos entre o trânsito e o crime atual, motivo pelo qual uma foi utilizada para fins de maus-antecedentes na fase anterior e outra como agravante da reincidência (págs. 21/22) nesta, não tendo atenuantes, de forma que as penas acima são novamente majoradas de 1/6, resultando em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e multa pecuniária em 680 dias-multa.

#### III- PENA DEFINITIVA

Não há circunstâncias especiais ou gerais capazes de ensejar o aumento ou diminuição das penas até aqui encontradas, pelo que as torno definitivas no patamar fixado na fase anterior.

Saliento que o Réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei n. 11.343/06, levando-se em conta a quantidade de drogas apreendidas e o fato de que necessários requisitos cumulativos para a concessão da diminuição, sendo esses: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, não sendo o caso, devido ao Réu apresentar maus-antecedentes e reincidência, inclusive ESPECÍFICAS.

Veja-se, aliás, que se deve levar em conta a forma de acondicionamento de droga apreendida, característico do tráfico contumaz, lembrando que este é atividade complexa, estratificada e organizada, desde o plantio, refino e chegada aos pontos de tráfico.

DECIDO.

Posto isso, e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na denúncia de páginas 57 a 59, para o fim de CONDENAR o réu JOSE

EDUARDO NUNES, já qualificado, como incurso no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, caput, à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e multa pecuniária em 680 dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei n. 11.343/06).

#### REGIME CARCERÁRIO:

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, conforme antes examinado, do Código Penal, § 3º, do artigo 33, do mesmo Diploma Penal, à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, ante a nova redação do §1º, do inc. II, do art. 2º, da Lei 8.072/90, que apesar do art. 1º, inc. I, segunda parte, do mesmo Dispositivo, considerar crime comparado a hediondo o tráfico de entorpecentes, estabelece que as penas deverão ser cumpridas em regime INICIALMENTE FECHADO, então, o cumprimento das penas se dará dessa forma, obviamente ressalvada a competência do Juízo da Execução, na forma do art. 66 da Lei de Execuções Penais.

Quanto ao que preceitua o art. 387, §2º do CPP, deixo de aplicar neste momento. Isso porque, considerando, o teor do art. 2º, da Lei dos Crimes Hediondos<sup>1</sup>, que diz no § 1º que a pena será cumprida inicialmente no regime fechado, independe do quantum fixado (diferente dos crimes comuns), nada há o que se falar em, dado esse tempo da cautelar, de modificação do regime.

A doutrina de G. de Souza Nucci diz que não se trata de um juízo de execução, o qual haverá de ser feito pelo juiz competente no PEC extraído e encaminhado à VEC ao lá ter.

Vale dizer, conforme tal doutrina, a autorização legislativa é para um exame, quero crer, similar ao de detração, MAS APENAS para verificar o quantum de pena que resta do montante fixado em condenação e assim para observar, se nos termos do art. 33 do Código Penal, o resultante fica inferior a um determinado tempo (número de anos), quando não sendo o condenado reincidente e reunidas condições judiciais favoráveis como diz o Código (arts. 59 e 60), pode receber regime mais brando do que indicaria o total inicial absoluto fixado, ou seja, seria, por exemplo, passível um condenado a pena inferior a 8 anos (nesse caso mesmo que superior, descontado o tempo da cautelar, se assim resultasse inferior a 8 anos, aliás, como foi o exemplo doutrinário, se caberia, a critério do magistrado, o regime mais brando, mas não neste que é regime inicial fechado independente da pena, como visto).

Já detração propriamente e progressão, só pode ocorrer na VEC pelo juiz competente que a tudo observará (méritos do condenado, contraditório etc.).

Assim, reservo, conforme a Lei, o exame imediato quanto a isso àquele Juízo, sendo que já será pelo cumprimento dos, em tese, 2/5 ou 3/5 da pena - hediondo -

(examinando sobre o comportamento carcerário do condenado e o juízo de progressão/merecimento), pois seria temerário conceder neste momento, em crime que exija o regime mais gravoso, a quem não o mereça pelo eventual mau comportamento, aliás, e se fosse nessa extensão, os poderes do juiz do conhecimento deveriam ser realmente dilargados para a detração e progressão mesmo e ele careceria, ainda, de elementos pelo Estado para a plena aplicabilidade na prática dessa possibilidade, ou seja, a criação de um sistema de consultas on-line para no momento da sentença observar-se eventual falta grave da Ré preso provisório durante a cautela (modo contrário, correria o magistrado risco de, repiso, conceder algo que redunde na soltura imediata do condenado que, por exemplo, tenha liderado rebelião ou mesmo atacado colegas de cela em clara demonstração de abominável comportamento carcerário).

Veja-se decisão no TJSP confirmando entendimento, recurso de decisão deste mesmo prolator:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação n. 0009028-

26.2014.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO N. 30.286 - RELATOR IVAN SARTORI:

"... Por derradeiro, o pedido de detração, com vistas a regime mais brando, é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, pese o disposto na Lei 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387 do CPP. É que, para progressão de regime, necessário bem avaliar os requisitos pertinentes, sem falar na possibilidade de supressão de um grau de jurisdição, em ofensa a princípio constitucional. Nessa linha, julgados desta Casa de Justiça: "(...) embora não se desconheça o teor da Lei n. 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao artigo 387, do

Código de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos recorrentes, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à mingua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição (...)." (Apelação n. 0009573-71.2012.8.26.0348, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juvenal Duarte, j. 13.02.2014); "(...) com relação à detração penal, tem-se que o Juízo de origem ainda não conheceu desta questão. Por esta razão, não se pode, nesta Instância Judicial, suprimir-se, de uma só vez, o devido processo legal (cf. artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), a manifestação do Juiz Natural (cf. artigo 5º, inciso LIII, da CF) e a garantia ao duplo grau de jurisdição (cf. artigo 5º, inciso LV, da CF), sob pena de vilipêndio à Lei Maior do País. Tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a ser produzida no Juízo das Execuções até porque continua vigente o artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei 7.210/1984, a par do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/2012 quando já presentes informações precisas para o exame com a minúcia necessária da situação prisional do acusado, para que repercuta na fixação do regime carcerário" (Apelação n. 0078884-36.2012.8.26.0224, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Roberto Solimene, j. 06.02.2014). Em suma: mantém-se o r. édito monocrático, encampada sua motivação (art. 252 RITJ). Ivan Sartori – Desembargador Relator".

#### SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Originariamente não se apresentava possível à substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito, já que em crimes da espécie a lei especial vedava expressamente, mas foi suspenso pelo Senado esta parte. Ipsis litteris:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012).

Porém, in concreto, não se apresenta possível à substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito devido à quantidade de pena, que se resultou superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I do Código Penal), devido ao Réu apresentar maus-antecedentes e reincidência, inclusive ESPECÍFICAS

#### SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

O crime pelo qual restou condenado o Réu tem vedação expressa do benefício do sursis, independentemente do quantum da pena imposta, a qual na maioria das vezes também impede a obtenção do benefício, como no caso em questão (art. 44, da lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 e 77, do Código Penal). Também novamente devido ao Réu apresentar maus-antecedentes e reincidência, inclusive ESPECÍFICAS

#### DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE:

Considerando que o Réu respondeu a todo o processo preso, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, conforme é o entendimento correntio da jurisprudência nacional.

Após o trânsito em julgado lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República).

Deixo de condenar o Réu em custas processuais, conforme alínea "a", do parágrafo 9º, do art. 4º, da Lei Estadual n. 11.608, de 29 de dezembro de 2003, porque assistido por advogado nomeado pelo convênio DPE/OAB.

P.R.I.

Guaratinguetá, 09 de setembro de 2022.